رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٢٤ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٢٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٩هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - أجرة المثل - منع مالك العقار من الانتفاع بعقاره قبل تسلُّم التعويض - موجبات الضمان - تعريف المنفعة - صور تفويت المنفعة - الحيلولة بين المنفعة ومالكها - نزع الملكية قبل صدور الأنظمة الحاكمة للنزع - عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي - تعويض - الاستئناس برأي الخبير - أتعاب الخبير - تكييف نزع الملكية للمنفعة العامة - التفرقة بين الاقطاع المطلق والاقطاع الزراعي - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها بأجرة المثل جراء منعها من الانتفاع بأرضها لوقوعها ضمن حدود المطار - الثابت قيام المدعى عليها بوضع يدها على أرض المدعية لتخصيصها ضمن أرض المطار بناء على أمر سامٍ، ودون تعويض المدعية عن نزع ملكيتها - تكييف الدعوى بأنها من دعاوى التعويض لنشوء محلها قبل صدور أنظمة نزع الملكية والتي لا تسري بأثر رجعي - تملك المدعية للأرض كان عن طريق الهبة من والدها الذي تملكها عن طريق الإقطاع ودون إحيائها - الإقطاع المطلق يثبت فيه التملك بمجرد الإقطاع، كالإقطاع السكني، والذي هو على غير الإقطاع الزراعي الذي يشترط فيه الإحياء للتملك؛ مما يكون أصل تملك أرض

المدعية قائماً على وجه معتبر - استحقاق أجرة المثل عن الأرض الفضاء يتطلب له توافر ثلاثة شروط، وهي المنع من الانتفاع، ويد الضمان، وتحقق المنفعة بحيث تصح إجارة الأرض - ثبوت توافر شروط استحقاق أجرة المثل على أرض المدعية؛ مما يتقرر استحقاق المدعية لأجرة المثل وفق تقدير الخبير - استحقاق المدعية التعويض عن ما دفعته للخبير - عدم قبول الدفع بأن الأجر والضمان لا يجتمعان؛ كون موجب الأجرة هو تفويت المنافع، وموجب الضمان هو الاستيلاء على العين - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.

دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها بأجرة المثل جراء منعها من الانتفاع بأرضها - تضمن النظام عدم سماع دعاوى التعويض بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به - الثابت مضي المدة النظامية لسماع الدعوى قبل تقدُّم المدعية بها - أثر ذلك: عدم سماع الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأجر والضمان لا يجتمعان).
- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٦هـ.

- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- المادة (٢٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٠) وتاريخ ١٣٩٦/٧/١٦هـ، بشأن الموافقة على قرار الهيئة القضائية العليا المتضمن أن الإقطاع يفيد التملك ما لم يتضمن شرط معتبر.
- المادة (١) من قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٩) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٢٩) في الدورة رقم (٤)، بشأن نزع الملكية للمصلحة العامة.

الوَقَائِع

بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، أقامت المدعية دعواها طالبةً الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضها بأجرة المثل جراء وضع مطار الملك عبد العزيز يده على أرضها المملوكة لها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢٥هـ، ومنعها من الانتفاع بأرضها حتى تاريخ ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ، المنتقلة إليها بطريق الهبة من والدها (...) صاحب الصك الصادر بتاريخ ١٣٨١/٤/٢٠هـ. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مدون في

محاضر جلساتها، وفيها سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلب مهلةً لتحديد فترة المطالبة، فأمهلته الدائرة. وبجلسة أخرى حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها تعويضها بأجرة المثل عن الفترة من ١٣٩٦/٦/٢٥هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جوابيةً تضمنت: أنه بناءً على رقم الصك وتاريخه الذي ذكره وكيل المدعية يتبين منه أن تملك المدعية للأرض محل الدعوى أتى في زمن لاحق لتخصيص الأرض كمرفق عام، وهذا ما يؤكده الأمر السامي رقم (٦٢٥٢/أ/٣) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٨هـ الذي نص على أن: "الصكوك الصادرة بعد تاريخ ١٣٨٥/٣/١٩هـ، تعتبر صادرةً على أرض حكومية مخصصة لمرافق عامة ويعتبر تطبيقها وإصدارها على هذه الأراضي أمراً واقعاً في غير محله وينظر في تطبيقها في أماكن أخرى"، كما أن الأمر السامي رقم (١٨١٢٦) وتاريخ ١٤٠٢/٧/٣٠هـ تضمن تعويض أصحاب الصكوك الصادرة بعد تاريخ ١٣٨٥/٣/١٩هـ بأراضٍ بديلة سواءً في مدينة جدة أو غيرها من المدن، طالباً في ختام مذكرته القضاء بعدم قبول الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية: هل صدر لموكلته التعويض بأرض بديلة؟ وهل لديه ما يثبت مطالبة المدعى عليها بالتعويض طيلة فترة المطالبة؟ فأجاب بمذكرة جاء فيها: أنه سبق وأن تمت مطالبة المدعى عليها بالتعويض بموجب خطاب التظلم رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٦هـ -لم يرفق ما يثبته- وأضاف أن الأرض مملوكة لـ(...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٨٢/٨/٢٤هـ وذلك قبل تخصيص أراضي

المطار. وعقب ممثل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: أن المدعية أقامت دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض عن الجزء المستقطع من عقارها محل الدعوى ولم يتم الفصل فيها، طالباً الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان. فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. وبعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، أشرعت الدائرة باب المرافعة وتمسك الأطراف بما سبق، وقررت الدائرة ندب مكتب (...) للتقييم العقاري خبيراً لتقدير أجرة المثل للفترة من ١٤٣١/٠٢/١٥هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ للعقار المملوك للمدعية، على أن تدفع المدعية الأتعاب، ويتحملها مآلاً الطرف المحكوم عليه، وقد ورد تقرير الخبير بتقدير أجرة المثل بأجرة قدرها (٢٨,٢١٣,٠٢٧) ثمانية وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة عشر ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت حقيقة دعوى المدعية هي إلزام المدعى عليها تعويضها بأجرة المثل عن الفترة من ١٣٩٦/٦/٢٥هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ لعقارها الواقع ضمن حدود مطار الملك عبد العزيز؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، وحيث إن تملك الجهة للعقار كان بموجب تخصيص الأرض محل النزاع للمطار بتاريخ ١٣٨٥/٣/١٩هـ، الذي كشف عنه الأمر السامي رقم (٣/أ/٦٢٥٢) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٨هـ، حيث نص على أن: "الصكوك الصادرة قبل ١٣٨٥/٣/١٩هـ تعتبر صادرةً قبل اختيار الموقع، ويستحق أصحابها التعويض"، وقد صدر صك والد المدعية (...) -الذي تفرع عنه صك المدعية- بتاريخ ١٣٨١/٤/٢٠هـ، وانتقل إليها جزء منه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢٥هـ، وقد منعها ذلك من الانتفاع بأرضها ولم تستلم التعويض، وكان ابتداء ذلك بأمرٍ خاصٍ قبل صدور الأنظمة المتعلقة بنزع الملكية؛ فتكون من دعاوى التعويض، ولئن كان تخصيص الأرض للجهة نزعاً للملكية في الحقيقة، لكن أحكام نظام نزع الملكية -الذي جاء بترتيب الولاية في نظر هذه الطلبات- لا تطبق عليها؛ لأن الأصل عدم رجعية الأنظمة والقرارات واقتصارُها على ما يلي صدورها، فلا تنعطف على ما سبق صدورها من وقائع إلا إذا نصّ على ذلك، ولم يرد ما يخرجها عن هذا الأصل. وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن قبول

الدعوى شكلاً من جهة الصفة، فلما كانت الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة الواضعة يدها على العقار محل الدعوى؛ فإن المطالبة بأجرة المثل تكون في مواجهتها، ولا وجه لدفع ممثل المدعى عليها بانتفاء صفتها، وأن أمانة محافظة جدة هي صاحبة الصفة؛ إذ لم تضع الأمانة يدها على العقار. ولا ينال من ذلك صدور الأمر السامي رقم (٣/أ/٦٢٥٢) وتاريخ ١٣٨٩/٣/١٨هـ، وما استتبعه من برقية نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (٧٨٨٧٦) وتاريخ ١٤٠١/٤/١١هـ، بالمعالجة النظامية للمنازعات الناشئة حول أراضي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فإنها متعلقة بالمسؤولية عن التعويض في أعيان العقارات باختصاص أمانة محافظة جدة خروجاً عن الأصل، أما منافعها فهي على الأصل في تضمين الجهة المنتفعة بها، ولم يرد ما يغير هذه الصفة. أما من جهة المدد المضروبة لسماع الدعوى، فالمدعية تطلب إلزام المدعى عليها تعويضها بأجرة المثل عن الفترة من ١٣٩٦/٦/٢٥هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ، وأقامت دعواها بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥هـ، وقد نصت الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وقد تقرر أن الدعوى من قبيل دعاوى التعويض، فتكون المدة السابقة لتاريخ ١٤٣١/٢/١٥هـ غير مسموعة، وما بعدها مسموع لكونها رفعت في المدة النظامية المنصوص عليها، ولا

وجه لفرز المدد السابقة لنظام النزع الحالي بالتفريق بين ما كان قبل صدوره وما بعده؛ لأن أخذ العقار من المدعية ليس بمستند إلى أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، ولا أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٦هـ؛ لوقوع الأخذ قبل صدورهما. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها بأجرة المثل عن الفترة من ١٣٩٦/٦/٢٥هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ لعقارها الواقع ضمن حدود مطار الملك عبد العزيز، والثابت أن ملك المدعية للعقار محل الدعوى ثبت بطريق الهبة من والدها، وقد كان تملكه له بطريق الإقطاع، ولم يثبت إحياؤه لها، وحيث إن الإقطاع المطلق الذي لم يشترط فيه الإحياء يثبت فيه الملك بمجرد الإقطاع، ولا يفتقر للإحياء؛ فيجوز بيع الأرض المقطعة والتصرف بها بمجرد الإقطاع، ولا تسترجع، وهذا مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، وعلى ذلك جرى المنظم في الإقطاع السكني -بخلاف الزراعي الوارد في نظام توزيع الأراضي البور- وقد صدر بذلك قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٠) في ١٣٩٦/٧/١٦هـ المتضمن الموافقة على قرار الهيئة القضائية العليا في: "أن عمل الحكومة قديماً وحديثاً في اعتبار الإقطاع مفيداً للتملك، وأنها تُصدر وثائق الإقطاع، وتكتب الجهات الرسمية للمحاكم لإعطاء المقطَعين حجج الاستحكام على الأراضي المقطعة لهم، بناءً على الأوامر السامية، فيبيعون تلك الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة، وتشتري في بعض الحالات الحكومة

منهم، وليس في عمل الحكومة هذا ما يخالف الشرع بل تشهد له القواعد الشرعية، وبناءً على ما تقدم فإن الهيئة ترى بأن الإقطاع يفيد التملك، وهو الذي عليه العمل الجاري في المملكة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بألا يملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبراً ولا يتحقق ملك بدونه"؛ وعليه ثبت تملك الواهب للعقار على وجه معتبر. وقد انتقل الملك للمدعية بطريق الهبة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢٥هـ، وثبت ملكها عليه. والثابت أن وضع الجهة يدها على العقار كان بموجب تخصيص الأرض محل النزاع للمطار بتاريخ ١٣٨٥/٣/١٩هـ الذي كشف عنه الأمر السامي رقم (٦٢٥٢/أ/٣) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٨هـ، وفيه: "أن الصكوك الصادرة قبل ١٣٨٥/٣/١٩هـ تعتبر صادرة قبل اختيار الموقع، ويستحق أصحابها التعويض"، ولقد صدر الصك الذي تفرع عنه صك المدعية بتاريخ ١٣٨١/٤/٢٠هـ الذي كان بالإقطاع، ثم انتقل جزء منه بالهبة للمدعية بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢٥هـ، وقد مُنعت المدعية من الانتفاع بأرضها لاسترسال المدعى عليها في وضع يدها بتخصيص الأرض لها، مع كونها أرضاً فضاءً وقت وضع اليد، ولم تستلم المدعية التعويض عن نزع العقار. ولما كان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من قبيل التمليكات القهرية المشروعة لإزالة الضرر وتحقيق المصالح العامة، فهي عقود قهرية، البيع فيها جبري يراعى فيه قيام أركانه من العاقدين والعوضين والصيغة، وتوافر شرائطه ومنها الرضا، لكن جُوّز فيه الإكراه واعتبرت عبارةُ المكرَه؛ لكونه مكرهاً بحق، فهو نوع من الجبر الشرعي، وقرر ابن رجب في القاعدة (٢٣) أن

من حَرُمَ عليه الامتناعُ من بذل شيء سُئِله فامتنع، وكان المطلوب منه تصرفاً بعقدٍ أو فسخٍ أو غيرهما، اعتُبر إذنُه، ويُجبره الحاكم عليه. وجاء في الإقناع وشرحه: "فإن كانا (أي المتبايعان) أو كان أحدهما مكرهاً لم يصح البيع إلا أن يكره بحق فيصح العقد؛ لأنه قولٌ حُمِل عليه بحقّ فصح". وقال الخرَشي: "ومن الإكراه بحق، الجبر على بيعِ الأرض للطريق، أو لتوسيعِ المسجد، والطعام إذا احتيج إليه"؛ وبناءً على ما تقدم فإن عبارة المكره بحق معتبرة في العقد من حيث الأصل، فإن امتنع قام الحاكم مقامه وتولى العقد. وإذ تقرر ذلك؛ فإن الفقهاء اختلفوا في العقود القهرية ومنها التمليكات المشروعة لإزالة ضررٍ ما؛ كالأخذ بالشفعة وأخذ الزرع من الغاصب، هل يتوقف التملك فيها على دفع الثمن أو يقع بدونه مضموناً في الذمة؟ والمختار أن التملك فيها يتوقف على دفع الثمن، فلا يكون له استقلال بالتملك والتمليك إلا ببذل الثمن، وهو مقتضى قول أبي حنيفة، وأحد قولي المالكية، وبه قال الشافعي في قول له، وهو وجه في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في الإنصاف، قال ابن رجب في تقرير القواعد وتحرير الفوائد معلِّلاً له: "لأن التسليطَ على انتزاعِ الأموالِ قهراً إن لم يقترن به دفعُ العوض وإلا حصل به ضرر، وأصلُ الانتزاعِ القهري إنما شُرع لدفع الضرر، والضررُ لا يزال بالضرر"، وهذا المعنى الذي عَلل به أشدُّ ظهوراً في نزع الملكية؛ إذ العُلَق في النزع منقطعة بين النازع والمنزوع؛ بخلاف غيرها من الشفعة والفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن ونحوهما، فإن العُلَق لم تنقطع فيها. وقد قرر هذا القول واضعو مجلة الأحكام العدلية في (م: ١٢١٦) فقالوا:

"لدى الحاجة يُؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان، ويُلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤدَّ له الثمن". وجاء ما يقرر ذلك في قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي رقم (٢٩) فنص على أنه: "لا يجوز نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية..."، ومنها: "أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل... فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم"، ولذلك فإن الملك لا ينتقل إلا بدفع القيمة لمالك العقار، ويكون وضع الجهة يدها عليه قبل ذلك موجِباً لأجرة المثل؛ لأن ما اشترط القبض لصحة عقده، لا يصح التصرف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوت الملك عليه. أما عن استحقاق المدعية لأجرة المثل مع كون عقارها أرضاً فضاءً؛ فلا بدّ له من ثلاثة شروط: الأول: (ثبوت منعها من الانتفاع بأرضها من قبل الجهة). الثاني: (كون يد الجهة يد ضمان). الثالث: (كون العقار له منفعة تصح إجارتها). فأما الأول: (ثبوت منعها من الانتفاع بأرضها)، فالثابت أن وضع الجهة يدها على العقار كان بموجب تخصيص الأرض محل النزاع للمطار بتاريخ ١٣٨٥/٣/١٩هـ، الذي كشف عنه الأمر السامي رقم (٦٢٥٢/أ/٣) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٨هـ، وفيه: "أن الصكوك الصادرة قبل ١٣٨٥/٣/١٩هـ تعتبر صادرة قبل اختيار الموقع، ويستحق أصحابها التعويض"، ولقد صدر الصك الذي تفرع عنه صك المدعية بتاريخ ١٣٨١/٤/٢٠هـ، الذي كان بالإقطاع، ثم انتقل جزء منه بالهبة للمدعية بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢٥هـ،

فإن الجهة تمنعها من الانتفاع من العقار بموجَب ذلك. وأما الثاني: (كون يد الجهة يد ضمان) فقد تقرر أنه ليس للجهة أن تضع يدها على العقار قبل قبض الثمن؛ لأن ما اشترط القبض لصحته من العقود، لا يصح التصرف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوت الملك؛ وعليه فتكون مستحقةً لأجرة المثل بوضع الجهة يدها على عقار المدعية من جهة أن الفقهاء قرروا أن للضمان أسباباً هي (العقد واليد والإتلاف)، وضمان المدعى عليها بسبب اليد، وما قبض بلا عقد ولا إذن يكون مضموناً كما في الإجارة الفاسدة؛ فتلزمها أجرة المثل لمدة بقاء العقار في يدها قبل العقد؛ لأن المنافع تلفت تحت يدها، قال في الروض المربع: "(ومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة وفرغت المدة، لزمه أجرة المثل)، لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر، فرجع إلى قيمتها". وأما الثالث: (كون العقار له منفعة تصح إجارتها)، والمنفعة -كما عرفها علي حيدر في درر الحكام- هي: (الفائدة التي تحصل باستعمال العين)، وقد رتب الفقهاء ضمان المنافع على ما كان له منافع تصح إجارتها، قال في كشاف القناع: "(وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها) يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب أو غيره (المنافع أو تركها تذهب)؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان". وتضمن منافع ما تصح إجارته في حال الفوات بأن تركت المنافع تذهب سدى، أو حال التفويت بأن يستوفي الغاصب منافعها، قال في المنتهى وشرحه: "(منافع المغصوب تضمن بالفوات

والتفويت)، والغصب وإن كان موجباً للضمان، فالموجب غير منحصر فيه"، والثابت هنا حكم الغصب لا حقيقته، وبينهما فرق، فلا يلزم من ثبوت الأول ثبوت الثاني؛ ومن هذا يتبين أنه ليس من شرط وجود المنفعة انتفاعُ مالك العقار بها؛ لأن التفويت -كما قرر العز بن عبد السلام- ضربان: تفويت الإتلاف. وتفويت الحيلولة. وتفويت الأرض الفضاء من قبيل الحيلولة، والأصل أن العقارات لها منفعة تعرف بقيمة أجرتها عند الناس لو أجرت، يستحقها صاحب العقار متى حيل بينه وبين عقاره، وهذا الذي قرروه تدخل فيه الأرض الفضاء. كما أن القول باشتراط كون العقار المنزوع معموراً؛ مردود في البحث الدلالي للألفاظ، من جهة أن لفظ (العقار) لغة هو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر كالأرض والدار -كما في (م: ١٢٩) من مجلة الأحكام العدلية-، وقد جاء في المادة (٣/١٧) مفرداً محلى باللام وهو من صيغ العموم، فأفاد الشمول لكل العقارات، وأيضاً فإن المقرر أن ما كان عاماً في أشخاص شيء كان عاماً في أحواله؛ فعمومه لأشخاص العقار يستلزم عمومه لأحواله فضاءً كان أو معموراً أو غير ذلك. ولا وجه لمن قال بقاعدة الحنفية بأن: (الأجر والضمان لا يجتمعان)؛ لأن موجب الأجرة هو تفويت المنافع، وموجِب الضمان الاستيلاء على العين، فالجهة منفكة، وقد قال الجمهور باجتماعهما. ويلزم من لم يحكم بأجرة المثل في الأرض الفضاء استناداً إلى قاعدة (الأجر والضمان لا يجتمعان) ألا يحكم بها في العمران؛ لأنها تشمله عند من قال بها، فيلزم من أخذ بها إعمالُ مقتضاها -عند من قررها- وطردُه في المعمور وعدمُ قصرِه على الفضاء؛ لأن من قال

بها بناها على أن منافع المغصوب غير مضمونة؛ لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراضٌ غير باقية، وإنما تقومُ بعقدِ الإجارة على خلاف القياس؛ لمكان الحاجة الضرورية إليها، وعقدُ الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجِر ضامناً بل يرتفع؛ إذ لا يمكن اعتباره مستأجِراً أميناً، وغاصباً ضميناً في آنٍ واحد لتنافي الحالتين. وعليه فقد ثبت أصل الاستحقاق لأجرة المثل، ولما كان الحكم بها متوقفاً على رأي الخبير، ولقد كان الاعتماد على رأي الخبراء في الأقضية لبيان ثبوت متعلقها أو حقيقتها أو قسمتها أو تقويمها من أوجه تحقيق المناط التي يرجع فيها إلى من كان خبيراً عارفاً بها، واستناداً إلى المادة (٢٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، التي نصت على أن: "يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم"، فأصدر مجلس القضاء الإداري (قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم)، والتي نصت في المادة الأولى على أن: "للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة"، ولما كانت الخصومة محل النظر مفتقرة إلى رأي خبير لتقدير أجرة المثل في الفترة المسموعة، ندبت الدائرة خبيراً في الدعوى لتقدير أجرة المثل للفترة المسموعة من ١٤٣١/٢/١٥هـ إلى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ للعقار المملوك للمدعية، على أن تدفع المدعية الأتعاب، ويتحملها مآلاً الطرف المحكوم عليه، وقد ورد تقرير الخبير بتقدير أجرة المثل للفترة من ١٤٣١/٢/١٥هـ إلى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ بأجرة قدرها (٢٨,٢١٣,٠٢٧) ثمانية وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة عشر ألفاً وسبعة

وعشرون ريالاً، وحيث ركنت الدائرة لرأي الخبير، ولم يبد الأطراف ما يخدشه، فإنها تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأجرة المثل المقدرة في المدة المسموعة. وحيث انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة؛ فإنه يلزمها بناءً على ما تقدم دفع تكاليف أتعاب الخبير في الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: عدم سماع الدعوى فيما قبل ١٤٣١/٢/١٥هـ. ثانياً: إلزام الهيئة العامة للطيران المدني أن تدفع لـ(...) أجرة المثل لعقارها المملوك لها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢٥هـ، للفترة من ١٤٣١/٢/١٥هـ وحتى ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ، وقدرها (٢٨,٢١٣,٠٢٧) ثمانية وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة عشر ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً. ثالثاً: إلزام الهيئة العامة للطيران المدني أن تدفع لـ(...) تكاليف أعمال الخبير وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.